

1520684-32.2021.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Eduardo Lora Franco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... sem indicação de ligação com o tráfico organizado. Já, quando se evidencia que aquela não seria uma ação isolada de tráfico, mas sim algo que iria se repetir, ou mesmo atingir mais de uma pessoa, como no caso de alguém surpreendido com diversas porções num local conhecido como ponto de tráfico, então a redução deve ser menor. Pior ainda quando há também a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

3ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1520684-32.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1520684-32.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Réu:

ROSIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA e outro

Vistos, etc.

Rosivaldo de Sousa Oliveira e Carlos Daniel Firmino dos Santos, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de agosto de 2021, durante calamidade pública e pandemia decretada pelo Governo do Estado de São Paulo em virtude do Covid-19, por volta das 05 horas, na Avenida Humberto Gomes Gaia, 134, Brasilândia, nesta cidade e comarca de São Paulo, ROSIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA, qualificado a fls. 14/15, agindo em concurso e em unidade de desígnios com seu comparsa e CARLOS DANIEL FIRMINO DOS SANTOS, qualificado a fls. 13, traziam consigo e guardavam, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros (tráfico), 15 invólucros plásticos, pesando cerca de 40 gramas contendo Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecido como Maconha e 70 invólucros plásticos contendo cerca de 46,15 gramas de cocaína, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica (cf. auto de apreensão de fls. 8/9 e laudo de constatação provisória a fls.33/36), além de dinheiro, celular e anotações de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, policiais estavam em patrulhamento no local dos fatos, quando avistaram um grupo de quatro pessoas dentre eles os denunciados, sendo que Rosivaldo carregava um estojo preto. Desta forma, resolveram abordá-los, tendo o grupo se evadido correndo em direção a um quintal. Iniciou-se breve perseguição, tendo os denunciados ingressado na residência de Carlos, e os demais empreendido fuga com êxito. Após franqueada a entrada dos policiais, estes encontraram Rosivaldo escondido no banheiro.

Em revista pessoal, lograram encontrar com o denunciado Carlos dois celulares, a quantia de R\$ 56,00, e com o denunciado Rosivaldo foi encontrado R\$100,00.

Rosivaldo indicou ainda que tinha escondido o estojo dentro do fogão, onde foi localizado pelos policiais, dentro do qual estava acondicionada a droga acima descrita.

Informalmente Rosivaldo confessou que estaria na venda de entorpecentes pelo local pela quantia de RS 300,00 e o denunciado Carlos não informou quanto ganharia na atividade.

A quantidade e variedade da droga, bem como a conduta dos denunciados, a folha de anotações de contabilidade de tráfico e o dinheiro encontrado denotam que se tratava destinada ao comércio ilícito de droga.

Diante do exposto, denuncio ROSIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA e CARLOS DANIEL FIRMINO DOS SANTOS como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei Federal 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal e requeiro que, recebida a autuada a presente, instaure-se o devido processo legal, prosseguindo-se de acordo com o rito previsto nos artigos 48 e seguintes da referida lei, com oitiva das testemunhas e interrogatório do réu, até final condenação. "

Determinada a notificação do(a)(s) acusado(a)(s) (fls. 121), houve resposta (fls. 258/260) e a denúncia foi definitivamente recebida (fls. 269/271). Em audiência foi colhida a prova oral e o(a)(s) ré(u)(s) interrogado(a)(s), tendo as partes se manifestado em debates. Há laudo de exame do entorpecente a fls. 136/137 e das anotações a fls. 170/180.

É o relatório.

Decido.

A procedência da ação é de rigor, posto que autoria e materialidade estão suficientemente comprovadas, mas apenas em relação a Rosivaldo.

A prova dos autos demonstra de forma cabal que o réu praticou os fatos imputados na denúncia, não merecendo acolhida quaisquer pretensões de desqualificar a palavra dos policiais.

De fato, os policiais ouvidos, contra quem não há nada de concreto nos autos, não havendo assim razão para dar às palavras destes agentes públicos menos valor que às de qualquer outro cidadão, foram uníssonos ao afirmar que em um local conhecido pelo tráfico avistaram quatro pessoas, sendo duas das quais os réus, estes que correram, sendo perseguidos por Gustavo, tendo eles ingressado em uma casa, onde por fim foram detidos. Gustavo disse que Rosivaldo prontamente assumiu a prática de tráfico, indicando o local onde tinha escondido o estojo que continha entorpecentes, tendo ainda ambos os agentes confirmado que haviam visto ele com tal bolsa quando da fuga. Gustavo disse, ainda, que os réus informaram que a função de Carlos era de olheiro.

E não há nos autos a indicação de qualquer razão que teriam os policiais para cometerem crime e colocarem suas carreiras em risco, imputando aos réus, a quem sequer conheciam, crime que não tivesse praticado.

Ademais, alegações sobre a imprestabilidade dos depoimentos policiais ou a necessidade de depoimentos de outras pessoas, além de totalmente dissociadas da realidade (quem, em sã consciência, irá querer espontaneamente se envolver em uma acusação contra um suposto traficante, morando próximo ao local e estando sujeito a todo tipo de represálias, até porque, via de regra, trata-se de tráfico em pontos controlados por grupos criminosos?), já estão amplamente superadas pela jurisprudência, carecendo de maiores considerações.

Não há, portanto, qualquer razão para se desmerecer a palavra dos policiais.

Ainda, o laudo pericial atestou a natureza do entorpecente, e as circunstâncias do fato e da prisão do réu (especialmente a quantidade e forma de acondicionamento em porções separadas, além da variedade de substâncias) não deixam dúvidas de que se destinavam a fornecimento a terceiros, caracterizando assim o crime de tráfico, e sendo impossível a desclassificação do delito.

Ademais, a versão do acusado Rosivaldo em seu interrogatório restou isolada de comprovação nos autos, sem nenhum elemento idôneo que a corrobore, carecendo, portanto, de qualquer credibilidade, até porque não explica porque, sendo pessoa que nada portava, que não correu, e que não tinha antecedentes, teriam os policiais o acusado injustamente.

E a versão de Carlos sequer confirma a versão de Rosivaldo, evidenciando a mentira

falada.

Assim, postas as provas, tendo ambos os policiais dito que visualizaram Rosivaldo com a bolsa na qual foram encontrados os entorpecentes, não resta dúvida da prática de tráfico por ele, sendo de rigor sua condenação.

Já, no que toca a Carlos, ainda que provável que estivesse mesmo ali traficando com Rosivaldo, restando os indícios disso tão somente no fato de ter corrido, e na suposta informação informal dada a um dos policiais, mas sem que tenha sido visto com as drogas em qualquer momento, nem que tenha formalmente admitido, ou sido acusado pelo comparsa, tenho que resta um panorama com margem para dúvida, até porque negou a imputação em juízo, o que basta para impedir a condenação.

Por fim, observo que a negativa de Carlos quanto a ter autorizado a entrada dos policiais é irrelevante, seja porque não tem comprovação, seja especialmente porque a situação era de claro flagrante, já que pessoas estavam em um conhecido ponto de tráfico, e ao avistarem os policiais correram para dentro daquela casa, situação claramente indicativa de situação de flagrância, legitimando a ação policial imediata, independente de qualquer autorização.

Assim, certa a condenação de Rosivaldo pelo artigo 33 da Lei nº 11.343/06, passo a dosar a pena.

Na fase do artigo 59 do Código Penal, e atento ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, tenho que é necessária a fixação da pena base acima do piso legal.

O que indica a maior gravidade do delito, e recomenda uma exasperação da pena, é justamente a natureza e quantidade das substâncias apreendidas. Diversas são as substâncias que caracterizam entorpecentes. Contudo, dentro dessas, há algumas que são mais graves, seja por terem maior poder de gerar dependência, seja por serem mais nocivas ao organismo do usuário.

Não há dúvidas de que a cocaína causa dependência com muito mais facilidade que a maconha, assim como gera maiores consequências para o organismo do usuário. Já o crack ou a heroína são ainda muito piores, causando forte vício a partir de poucas utilizações e sendo extremamente nocivos à saúde do usuário.

Embora todas sejam substâncias entorpecentes submetidas à Lei de Tóxicos vigente, não se pode negar que possuem características, seja quanto ao grau de dependência, seja quanto à nocividade, muito diferentes entre si, não podendo ser consideradas de forma absolutamente indistinta na dosimetria da pena correspondente, justamente porque não se pode dar o mesmo tratamento a quem comercializa uma substância extremamente nociva e viciante em relação a outra pessoa que repassa outra substância muito menos danosa, dado que são condutas que atingem de forma diversa os usuários e a própria sociedade.

Assim, em sendo o delito de tráfico de substância mais grave, a pena a ser aplicada, para quem explora o vício e gosto dos usuários, deve ser maior.

E não é demais lembrar que, quanto mais forte a dependência gerada pela substância, mais crimes serão cometidos para sustentar o vício dos dependentes, implicando assim, como dito, numa maior gravidade não só para quem usa o entorpecente, mas sim para toda a sociedade.

Desta forma, tenho aplicado para o tráfico de maconha, droga esta menos nociva, a pena no mínimo legal. Já para o tráfico de cocaína, como no presente caso, aumento esta pena e, em se tratando de crack, aplico um aumento ainda maior, posto que a destruição nas vidas dos usuários desta substância, explorada pelo traficante, é muito maior.

Mas, além disso, há que se observar a razoável quantidade de entorpecente apreendida, totalizando 85 porções, podendo atingir um considerável número de usuários. Não se pode, portanto, punir este delito da mesma forma que se tivesse sido apreendido com o réu apenas uma dúzia de porções, por exemplo.

Assim, no caso dos autos, aumento a pena base do réu em um sexto acima do mínimo na fase do artigo 59 do Código Penal.

Ausentes agravantes ou atenuantes.

Quanto à agravante da prática do delito durante estado de calamidade, respeitado o entendimento do Ministério Público, penso que não é mais aplicável aos fatos praticados a partir de 2021, ao contrário dos delitos cometidos em 2020, após 20 de março.

É que naquela data (20/3/2020) foi editado o Decreto Legislativo Federal nº 6/2020, que reconheceu em âmbito nacional o estado de calamidade pública, com vigência até 31 de dezembro de 2020.

E tal estado de calamidade, no âmbito federal, não foi prorrogado em 2021.

É verdade que há também os Decretos Estadual nº 64.879/20, e Municipal nº 59.291, da mesma data, que, igualmente, reconhece, e declara, o estado de calamidade no estado e no município.

Porém, tais atos, no meu entender, estão vinculados ao decreto federal, e não produzem efeitos, para fins de agravamento de pena, a partir da cessação da vigência daquele.

É verdade que estados e municípios podem declarar estado de calamidade em nível local. Porém, em primeiro lugar, de se observar que o motivo do estado de calamidade, a saber, a pandemia de Covid-19, não é um fenômeno meramente local, e nem nacional, mas sim mundial.

E não faz sentido haver, apenas por isso, estado de calamidade meramente local.

Ademais, e esse é o ponto mais relevante, os decretos do estado e do município não mencionam prazo de validade, e não me parece razoável considerar-se válido um decreto de calamidade permanente, sem termo certo, ainda que prorrogável.

É justamente por este ponto, não conter prazo de validade, e terem sido editados exatamente no mesmo dia do decreto federal, que entendo que são derivados daquele, e dele dependentes, não produzindo o efeito de manter a situação excepcional de calamidade pública após o fim da vigência da norma nacional.

Por isso, pessoalmente, e admitindo plenamente entendimentos noutro sentido, tenho que não se caracteriza a agravante imputada para fatos praticados a partir de 1º de janeiro de 2021.

Sendo o réu primário à época dos fatos, não se podendo afirmar categoricamente que veio posteriormente a praticar o tráfico pelo qual está preso e condenado em primeiro grau, já que ainda não transitada esta condenação (feito nº 1527974-98.2021, disponível para consulta no e-SAJ), pela sua situação à época dos fatos faz jus ao redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao montante da redução, observo que se trata de questão polêmica, já que as circunstâncias que são utilizadas para a concessão ou não do benefício (primariedade, falta de antecedentes e não envolvimento com organizações criminosas nem se dedique a atividades desta natureza) são totalmente objetivas, e não admitem gradação. Ou seja, ou a pessoa atende integralmente aos requisitos, e faz jus ao benefício, ou não atende, e não faz jus. Não servem, portanto, para a escolha do montante de redução a ser aplicado.

Ademais, observo que não me parece que a intenção do legislador tenha sido a de beneficiar aqueles que realmente sejam traficantes “profissionais”, aplicando um pena inferior à que era aplicável na legislação anterior, o que ocorre quando utilizado o redutor em dois terços. Pelo contrário, tudo indica que tal benefício deva ser reservado, especialmente em seus patamares mais elevados, àquelas pessoas, que tenham vida correta, sem nenhuma propensão ao crime, mas que, num momento absolutamente isolado e ocasional, tenham vindo a praticar um delito de tráfico de menor gravidade.

Assim, considerando a natureza do benefício, tenho que se deve considerar para fixação do patamar de redução o grau de eventualidade do delito indicado pelas circunstâncias do fato. Ou seja, se as circunstâncias dos autos indicarem que aquela sem dúvida alguma foi um ação completamente isolada e ocasional, o redutor deve ser aproximar do máximo. Seria o caso, por exemplo, de alguém que tenha atividade profissional definida, e que numa situação completamente específica tenha aceitado, uma única vez, fazer o transporte de entorpecente para outrem, e em quantidade não elevada, sem indicação de ligação com o tráfico organizado. Já, quando se evidencia que aquela não seria uma ação isolada de tráfico, mas sim algo que iria se repetir, ou mesmo atingir mais de uma pessoa, como no caso de alguém surpreendido com diversas porções num local conhecido como ponto de tráfico, então a redução deve ser menor. Pior ainda quando há também a participação de olheiros, ou “contabilidade” de comercialização, que denotem a proximidade com maiores traficantes, hipótese em que a redução deve se aproximar do mínimo, ou sequer ser

aplicada, conforme as circunstâncias, se evidenciada a participação em organização criminosa.

No caso dos autos, o réu estava em típica situação de tráfico a varejo, denotando uma ação não absolutamente isolada e ocasional, mas sim que iria se repetir (inclusive como, ao que tudo indica, se repetiu, já que preso alguns meses depois por tráfico no mesmo local), razão pela qual a redução deve se afastar do piso. Porém, por outro lado, não há indicação de maior proximidade com outros delitos ou o grande tráfico, razão pela qual tenho como adequada e suficiente a redução pela metade.

Assim, finalizo a pena do réu em dois anos e onze meses de reclusão e 291 dias-multa.

Ante o total da pena, próximo do limite de impossibilidade de substituição e do regime aberto, bem como considerando a nova prisão do réu, a ausência de confissão, denotando o comprometimento de sua personalidade, e a natureza e demais circunstâncias do crime imputado, tenho como necessário o regime inicial semiaberto, bem como insuficiente a substituição da pena.

E pelas mesmas razões, ainda que o réu tenha respondido até o momento solto por este processo, tendo vindo a se envolver em nova acusação da mesma natureza, pela qual está preso atualmente, demonstrando propensão para o crime, fica evidente a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, evitando a prática de novos delitos, razão pela qual nego-lhe o direito de apelar solto. Observo, ademais, que para fins de ressocialização tal determinação é mais favorável para o réu, já que, se evitará a situação de vir a progredir de regime pelo outro processo mas, transitando em julgado esta condenação, vir a ter a reconstrução de sua vida prejudicada pelo regresso ao cárcere, sendo muito mais favorável o cumprimento desde logo, com progressão definitiva, oportunamente.

E tudo isso não esquecendo que não haverá nenhuma alteração em sua situação atual já que, como dito, já se encontra preso por outro processo.

Isto posto, julgo a presente ação PARCIALMENTE PROCEDENTE, para condenar Rosivaldo de Sousa Oliveira, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e 291 dias-multa, estes no mínimo legal. E ABSOLVO Carlos Daniel Firmino dos Santos, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O réu condenado não poderá apelar em liberdade, nos termos supra, ficando decretada sua prisão.

Expeça-se mandado de prisão, encaminhando-o ao local onde custodiado.

Não havendo impugnação ao laudo pericial, inexistindo assim dúvida sobre a natureza da droga e considerando as precárias condições de acondicionamento destas substâncias nas Delegacias de Polícia, determino que caso ainda não tenha sido feito, oficie-se, independente do trânsito em julgado, comunicando a autorização para incineração integral dos entorpecentes apreendidos, incluindo amostras.

Determino, outrossim, o perdimento dos valores apreendidos com Rosivaldo (R\$ 104,50) em favor da União, nos termos da Lei de Tóxicos, a ser comunicado após o trânsito em julgado.

Após o trânsito, restitua-se a Carlos os valores apreendidos com ele (R\$ 56,00), e oficie-se autorizando a devolução dos celulares, se comprovada a propriedade ou, na inércia, sua destruição, bem como também dos demais objetos sem valor econômico.

Custas pelo(a)s condenado(a)s, na forma do artigo 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03, observando que a gratuidade decorrente da atuação da Defensoria Pública não exclui a responsabilidade final, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º da Lei nº 13.105/15, que modificou a Lei nº 1.060/50, e que só se efetiva, por ser executada como dívida de valor, sobre o patrimônio do devedor, não implicando em nenhum risco à sua subsistência, podendo ser cobrada se demonstrada alteração de situação econômica.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de agosto de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Lora Franco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA